

1531091-97.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... de fato, praticaram a conduta de roubo consumado (vítima Marcos) que lhes é imputada pela acusação, imputação esta lastreada em vasto arcabouço probatório, restando bem provadas materialidade e autoria delitivas.

Quanto ao crime cometido contra Marcos, devem os acusados responder pela prática de roubo majorado pela comparsaria e pelo emprego de arma de fogo, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1531091-97.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531091-97.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDER GUILHERME FERREIRA PINTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

KEVIN ALEXANDRE SANTANA GANGI e WENDER GUILHERME FERREIRA PINTO foram denunciados e se veem processados pela prática dos crimes descritos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I (vítima Marcos) e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II (vítima Fabiana), na forma do art. 70, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos c/c art. 61, II, "j)" e c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal, porque, (i) no dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 19h50, no cruzamento da Rua Gal. Chagas Santos com a Rua Abrão de Moraes, Jardim Colina, nesta cidade, os acusados, previamente ajustados e com unidade desígnios com o adolescente Bruno da Silva Farias e mais um agente ainda não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, a motocicleta Suzuki JTA 1000 cilindradas, placa DZS 3888, além de uma mochila contendo um fone de ouvido, um estetoscópio, um par de óculos de grau, um carimbo com almofada, uma agenda e uma carregador de celular pertencentes a Marcos de Azevedo; (ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima, os réus, previamente ajustados e com unidade desígnios com o adolescente Bruno da Silva Farias e mais um agente ainda não identificado, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante emprego de arma, a motocicleta Honda XRE 190 SE, 300 cilindradas, pertencente a Fabiana Aparecida Dourado, somente não

consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade comum; e (iii) na mesma data e local supra, facilitaram a corrupção do adolescente Bruno da Silva Farias, de apenas 14 anos de idade, com este praticando os crimes supra.

Recebida a Denúncia, os acusados foram citados, apresentando Resposta Escrita à acusação.

Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogados os acionados.

Nos debates, a Acusação postulou a procedência do pedido, enquanto a Defensoria Pública sustentou a improcedência do pedido, deduzindo, ainda, teses subsidiárias. Em memoriais, a Defesa constituída apresentou pedido absolutório e teses subsidiárias.

É o relatório do quanto necessário.

O pedido é procedente em parte.

Interrogados na etapa policial, ambos os acusados optaram pelo silêncio, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 13 e 22).

Em Juízo, confessaram parcialmente as acusações, negando o emprego de arma de fogo, bem como a tentativa de roubo dos bens da vítima Fabiana.

Se colocaram no palco dos acontecimentos, e atuação conjunta do menor para pilhar o patrimônio alheio, mediante violência (moral).

Logo, fuge ao bom senso o argumento de que houve desrespeito ao disposto no art.

226, do CPP, o que traria dúvida, certo, ainda, que a simples impossibilidade momentânea da vítima proceder a reconhecimento em audiência, não maravilha, tampouco acanha a prova, máxime diante da própria afirmação da vítima de que, na data do fato, quando da prisão, não teve qualquer dúvida no ato de reconhecimento. Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a Juízo para depor acerca do ocorrido, a vítima Marcos de Azevedo declarou, à semelhança do informado na fase policial, que na data em questão, trafegava com sua motocicleta pela região dos fatos, quando o semáforo fechou. Ao seu lado parou também uma moça, igualmente a bordo de uma moto. Neste mesmo instante, surgiram três ou quatro indivíduos, e, da faixa de pedestres, gritaram “desce da moto, desce da moto”, sendo que um deles apontava uma arma em sua direção. Detalhou que a arma se tratava de um revólver e que seu tambor tinha a cor prateada. Relatou que um dos membros do grupo aparentava ser menor de idade. Atendeu imediatamente às exigências dos autores e desceu da moto, momento que foi revistado, e um dos indivíduos tirou a sua mochila, perguntando se era policial. Neste ínterim, a outra moça, que estava de moto a seu lado, tentou fugir, acelerando o motociclo dela em direção a um dos roubadores. Neste momento de tensão, e diante da tentativa da moça em sair do local, viu que um dos criminosos deu um tiro para o alto, o que possibilitou a sua fuga na direção de um posto de combustíveis onde se abrigou, sede em que ouviu uma série de disparos de arma de fogo, não sabendo quem os teria feito. Após cessarem os disparos, voltou para socorrer a moça, ocupante da outra moto, que viu caída no solo, tal como um dos autores, este com um tiro na perna e com fratura exposta decorrente do disparo, aparentando este ser o menor de idade. Informa que viu um sujeito que estava com um distintivo de polícia, de shorts ou bermuda, de tênis, com a arma apontada para o rapaz, o rendendo. Constatou que o seu motociclo havia sido levado por dois dos criminosos. Perguntou se a moça, outra vítima, estava bem, quando tomou conhecimento de que ela havia sido atingida nas costas por um tiro. Por ser médico, realizou alguns testes mexendo nas pernas da vítima, porém, ela disse que não as sentia. Ainda no local, tomou conhecimento de que sua motocicleta e sua mochila haviam sido recuperadas, tal como presos dois dos seus algozes, os quais reconheceu, sem sombra de dúvidas, na delegacia de polícia. Por fim, diante da dinâmica dos fatos, não percebeu se os criminosos também investiram na sanha roubadora contra a vítima Fabiana, ou se esta, frente a cena que viu, pretendeu sair em fuga para evitar fosse roubada.

A vítima Fabiana Aparecida Dourado, a vista do pedido de fls. 177/178, foi dispensada de sua oitiva em Juízo, ela que, também, não foi ouvida na etapa policial.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima Marcos são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia os réus anteriormente, não teria interesse de prejudicá-lo, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragoneses Alonso, Madrid; Reus, 1979, p. 290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá: Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

E, respaldando os relatos da vítima Marcos, temos as informações prestadas pelos policiais militares envolvidos com a ocorrência.

Inicialmente, foram tomadas as declarações de Maxwell Silva de Souza e Helton Ulloffo Moura Souza, tendo eles narrado, em uníssono, que estavam a bordo da viatura, em um posto de gasolina nas proximidades, momento em que visualizaram uma moto trafegando em alta velocidade, com dois indivíduos sem capacete. Ao mesmo tempo, um transeunte os avisou de que havia ocorrido um assalto ali próximo, e que duas vítimas haviam sido baleadas. Deslocaram-se, então, até o local indicado e se depararam com duas vítimas, sendo que uma delas, do sexo feminino, havia sido baleada nas costas. A outra vítima tratava-se de um homem, médico, em relação a quem os criminosos haviam logrado subtrair sua motocicleta. Também no local, havia um adolescente infrator, que, segundo as declarações das vítimas, participou do roubo e também se encontrava baleado. Quando chegaram, já havia sido acionado o resgate e, segundo as informações passadas para a equipe dos depoentes, outra equipe policial já estava em busca dos roubadores, os quais haviam empreendido fuga com a motocicleta da vítima Marcos.

Na sequência, as testemunhas Cleverson Quintana Constantino e Daniel de Amorim Gimenez, igualmente policiais militares envolvidos com os fatos, narraram, em

depoimentos absolutamente harmônicos, que se encontravam em patrulhamento pelas ruas desta urbe, quando foram acionados, via rádio, para atender à ocorrência versando sobre roubo de motociclo em andamento. Informam que havia outras equipes já empenhadas na ocorrência e, em virtude de o local do roubo ter sido próximo, diversas pessoas apontavam em direção a um motociclo acidentado e abandonado debaixo do viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, indicando, ainda, a direção em que os indivíduos teriam seguido. Localizaram, então, a motocicleta, deixada no chão da via, objeto do roubo irradiado. Segundo populares, a moto havia sido abandonada por dois indivíduos, os quais, após se acidentarem com o veículo, continuaram fuga a pé. Narram que saíram ao encalço dos suspeitos, e após diligências pelas imediações, lograram êxito em encontrá-los a aproximadamente 400/500 metros do local onde abandonaram o motociclo roubado, num bar. Ao abordarem os indivíduos, constataram que eles estavam com ferimentos condizentes com os de acidente de motociclo, vale dizer, ambos estavam com o corpo ralado. Foi proferida voz de prisão aos indivíduos, os quais confessaram o delito e foram imediatamente socorridos junto ao PS do Hospital Saboya. Após liberados, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a vítima Marcos os reconheceu como sendo autores do roubo.

É a prova oral.

Neste cenário, dúvida não paira de que os réus praticaram o crime de roubo descrito na Denúncia, contra a vítima Marcos, sendo a condenação medida de rigor. Consigno que nada há nos autos a indicar que a vítima Marcos ou os policiais militares, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar os acionados, sabendo se tratar de pessoas inocentes.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade da vítima ou das testemunhas, ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar os acusados.

Assim, tomo seus relatos como verdadeiros, mormente quando prestados de maneira harmônica e verossímil, em rememoração tranquila dos fatos em audiência, inclusive em linha com a parcial confissão dos acionados.

Da prova se extrai, portanto, que no dia, local e horário descritos na peça acusatória, os acusados, unidos entre si e com mais dois indivíduos, um deles menor de idade, identificado como Bruno da Silva Farias, com unidade de desígnios, voltados finalisticamente à prática de crimes de roubo, e valendo-se do emprego de uma arma de fogo, abordaram a vítima Marcos, tendo logrado subtrair a motocicleta e pertences pessoais.

Outrossim, em decorrência da participação do adolescente referido, respondem, também, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Ainda, consoante declarado em audiência pela vítima Marcos, o grupo portava uma arma de fogo, a qual empregaram para exercer a grave ameaça, inclusive realizando um disparo para o alto.

Desta maneira, conclui-se que os acusados, de fato, praticaram a conduta de roubo consumado (vítima Marcos) que lhes é imputada pela acusação, imputação esta lastreada em vasto arcabouço probatório, restando bem provadas materialidade e autoria delitivas.

Quanto ao crime cometido contra Marcos, devem os acusados responder pela prática de roubo majorado pela comparsaria e pelo emprego de arma de fogo, na modalidade consumada.

O concurso de pessoas é patente, presentes que estão todos os requisitos necessários para sua configuração, vale dizer, pluralidade de agentes; relevância causal das condutas para a produção do resultado; liame subjetivo entre os autores, eles, que unidos e com identidade de desígnios, visando à prática do crime em tela; unidade de infração penal executada por todos os agentes, em consonância com a teoria monista adotada pelo Código Penal (art. 29, caput, do CP); e, por fim, existência de fato punível, eis que o ajuste não se limitou ao plano intelectual, mas sim, foi colocado em prática, percorrendo os autores etapa do iter criminis suficiente para a perfeita configuração do crime pelo qual são acusados (art. 31 do CP).

Quanto à majorante decorrente do emprego de arma de fogo, válido registrar que a jurisprudência não exige seja a arma de fogo apreendida para que se reconheça a majorante em foco:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando outros elementos comprovem tal utilização.

Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)...O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.

Igualmente adequado o reconhecimento da majorante decorrente do emprego de arma (redação da Lei nº 13.654/18), porquanto a vítima foi contundente ao narrar que os roubadores a ameaçavam a todo tempo com o emprego de armas de fogo, até lograrem êxito na subtração de seu veículo. Anoto, neste ponto, que a não apreensão das armas de fogo não tem o condão de afastar referida majorante, que se encontra sobejamente calcada nos contundentes relatos dos ofendidos em Juízo.

No caso dos autos, sobram elementos a consubstanciar o entendimento de que os acusados e sua grei agiram munidos de arma de fogo real e com potencialidade lesiva, mormente quando a vítima ouvidas em Juízo declarou tal fato, tendo Marcos mencionado, ainda, que um dos agentes chegou a efetuar um disparo para o alto, de modo que reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ainda, com relação ao crime praticado em desfavor de Marcos, de rigor o reconhecimento de que a infração se consumou.

Neste sentido, é o entendimento encerrado na súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Trata-se, portanto, da prática de crime de roubo consumado, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Já com relação ao crime imputado aos acionados, tendo como vítima Fabiana, entendo que a prova é escassa, e não autoriza a condenação.

De início, bem de ver que referida vítima, alvejada que foi por terceiro incógnito que, provavelmente, pretendeu reagir ao assalto, não foi ouvida na fase policial. Oportunizada sua oitiva em Juízo, frente ao declarado a fls. 177/178, foi objeto de desistência pela parte Acusadora (fls. 182).

Muito embora na fase policial a vítima Marcos tenha dado contornos de que o grupo também avançou em assalto contra a vítima Fabiana (fls. 10), na audiência de instrução disse não ter condições de realizar tal afirmação.

Os policiais ouvidos, em número de quatro milicianos, sobre eventual informação da vítima Fabiana, de que o grupo também avançou em roubo contra seus bens, nada trouxeram.

Ou seja, não se sabe ao certo se, na cena dos fatos, os acionados e parceiros de crime também avançaram contra o patrimônio de Fabiana, de forma violenta, ensejando que ela, na pretensão de defender seu patrimônio, tivesse lançado seu motociclo

contra os algozes, ou se, Fabiana, vendo a cena de roubo violento contra Marcos, antes mesmo de ser tomada como vítima, pretendeu simplesmente sair do local, dando marcha em fuga.

Portanto, não tenho segurança a verificar que os réus e seu grupo também avançaram contra o patrimônio de Fabiana, donde a absolvição por tal acusação se impõe. Finalmente, tenho que a acusação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 também se confirmou, na medida em que apreendido o menor de idade Bruno da Silva Farias, que, à época dos fatos contava com apenas 14 (quatorze) anos, em situação absolutamente flagrancial, ainda no palco dos eventos, tendo ele participado de toda a empreitada criminosa ao lado dos ora acusados, como relatou a vítima Marcos, bem como admitiram os acionados.

Vale registrar que o crime em questão é do tipo formal, dispensando qualquer incursão acerca da vida pregressa do menor, no que diz respeito, especialmente, à anterior prática de ato infracional.

Noutros termos, a corrupção dos adolescentes é presumida absolutamente ex lege (iure et de iure).

Em tal sentido, preceitua a Súmula nº 500 do E. Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Desta forma, respondem os acusados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Marcos), bem como pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (menor infrator, Bruno da Silva Farias).

Bem divisada a responsabilidade dos acionados, passo a mensurar suas reprimendas. Em primeira fase de mensuração das reprimendas, em que pese a gravidade ínsita aos tipos penais violados, considero que os réus agiram com culpabilidade normal à espécie, motivo pelo qual fixo as penas de cada um dos crimes, e para cada acionado, no mínimo legal.

Em segunda fase, respeitado entendimento contrário, não lhes favorece a confissão, na medida em que parcial, sem qualquer tónus de arrependimento, mesmo porque, pretenderam minorar suas responsabilidades, sob a afirmação de que não utilizaram arma de fogo, o que contrasta com a séria afirmação da vítima Marcos em tal sentido, sendo certo que Kevin pretendeu afirmar que seu grupo teria usado um simulacro de arma, enquanto Wender, por sua vez, pretendeu indicar que a arma utilizada não funcionava.

Triste postura.

Doutro lado, verifico a presença de duas agravantes.

Inicialmente, consoante certidões de fls. 113/115 (KEVYN) e fls. 123/126 (WENDER), ambos os réus são reincidentes específicos, ou seja, anteriormente condenados em definitivo pela prática de crime de roubo, não tendo decorrido o período depurador quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do CP.

Não bastasse, ainda está presente a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j)", do Código Penal, tendo em conta a data do fato (23/12/2021) e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de modo que reconheço ter sido praticado o crime em reconhecido estado de calamidade pública, decorrente da notória pandemia do vírus COVID-19, circunstância de natureza objetiva.

Neste cenário, elevo as penas de ambos os réus no equivalente a $\frac{1}{4}$, fixando, a cada qual, (i) para cada o crime de roubo cometido em desfavor de Marcos, a pena de cinco anos de reclusão e pagamento de doze dias multa; e (ii) pelo crime de corrupção de menor, a pena privativa de liberdade de um ano e três meses de reclusão.

Em última fase de mensuração de reprimendas, no que tange ao crime de roubo, verifico que incide duas causas de aumento de penas, consistentes no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo.

Não obstante, de ponderação o quanto preceituado pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal, de maneira que aplico tão somente a segunda majorante, o que faz elevar as penas de cada um dos réus no equivalente a $\frac{2}{3}$, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

além do pagamento de 20 (vinte) dias multa.

De todo modo, reconheço o concurso formal entre todos os dois crimes pelos quais os réus se veem condenados, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, consoante entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. AÇÕES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

3. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

4. Ordem parcialmente concedida.

(...)

“No que se refere ao reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, melhor sorte assiste à defesa. Com efeito, conforme se extrai da descrição fática ilustrada no bojo do aresto vergastado e da exordial incoativa, o paciente, mediante uma única ação, praticou ambos os delitos e atingiu dois bens jurídicos diversos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Dessarte, na linha da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, incide no caso a regra do artigo 70 do Código Penal, aplicando-se a mais grave das penas cabíveis, aumentada de um sexto até metade. Nesse sentido, confirmam-se: (...)”.

Na mesma linha, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Prova segura. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento do concurso formal entre os delitos. Possibilidade. Regime inicial aberto e substituição por restritiva de direitos. Alteração da prestação pecuniária por multa, nos patamares mínimos. Recurso parcialmente provido.

(...)

“Por fim, deve ser reconhecido o concurso formal de infrações entre a corrupção de menor e o furto qualificado, como pleiteia a defesa, posto que, mediante uma só ação ou omissão, a ré praticou dois delitos, no mesmo contexto fático.”

Desta forma, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, seria de se aplicar aos acusados somente a pena corporal do crime mais grave, de roubo majorado e consumado, elevada, entretanto, em 1/6, em razão da quantidade de delitos

praticados, o que somaria, para cada réu, o cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 20 (vinte) dias multa. Entretanto, frente o comando que emerge do art. 70, § único, do Código Penal, aplico o disposto no art. 69, do mesmo regramento legal.

Penas finais: a cada qual dos acionados o cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 20 (vinte) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, reprimendas estas que torno definitivas, à mingua de circunstâncias modificadoras.

Os réus cumprirão as penas corporais impostas no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a)", do Código Penal, na medida em que a eles foi aplicada pena privativa de liberdade superior a oito anos de reclusão.

Outrossim, a reincidência, inclusive específica, que milita em desfavor de ambos os acusados, impede a fixação de regime prisional mais brando.

Por fim, de incidência, ainda, o disposto no § 1º, do art. 2º, da Lei Federal nº 8.072/90.

Assim, a culminar no caráter pedagógico da pena, e ultimando em reprovação eficaz, de molde a que os réus não mais permeiem os meandros da criminalidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal de ambos.

Outrossim, inviável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos, em tendo sido aplicadas aos réus penas privativas de liberdade muito superiores a quatro anos, decorrentes de crimes cometidos mediante grave ameaça à pessoa, sendo ambos os acusados reincidentes.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual dos acionados, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para ABSOLVER os acionados KEVIN ALEXANDRE SANTANA GANGI e WENDER GUILHERME FERREIRA PINTO da acusação de prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Fabiana Aparecida Dourado, o que faço com suporte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para CONDENAR os réus KEVIN ALEXANDRE SANTANA GANGI e WENDER GUILHERME FERREIRA PINTO, cada qual, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 20 (vinte) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo, ambos por infringência ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar dos acionados, consubstanciados na decisão que converteu suas prisões em flagrante em preventivas, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de forma que mantenho a custódia dos acusados, caso pretendam a via recursal.

Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados.

Arcarão os condenados com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06